

1501133-07.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

1501133-07.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501133-07.2021.8.26.0571 - 2021/001157

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL IGOR FERREIRA MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

RAFAEL IGOR FERREIRA MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 20 horas, na Rua José Ferreira Menke, nº 31, Jardim Nova Era, nesta cidade, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas consistentes em 20 pedras de "crack", com peso líquido de 3,13g, e 01 porção maior de "crack", droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina, avistaram um veículo com vários indivíduos, dentre eles o denunciado, razão pela qual decidiram abordá-lo; que os policiais efetuaram revista pessoal, sendo que encontraram com o denunciado 20 pedras de "crack" e mais 01 porção maior de "crack".

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls. 15.

Laudo de exame pericial provisório à fls. 18/19 e definitiva à fls.83/86, com resultado positivo para cocaína.

Notificação do réu nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls.108, com apresentação de defesa preliminar à fls.122/123.

Denúncia recebida à fls.128, em 22 de março de 2022.

Na audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, foi decretada a revelia do réu, seguida da oitiva de uma testemunha de acusação, arrolada em comum pela defesa; havendo desistência em relação às demais, fls. 160/167.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa arguiu preliminarmente a nulidade da busca veicular e pessoal com o desentranhamento da prova ilícita e, no mérito pugnou pela absolvição por ausência de provas, pleiteando a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei de Tóxico e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; o reconhecimento da causa de diminuição; a fixação do regime menos severo.

O feito foi sentenciado e devidamente instruído o recurso a sentença foi anulada para que outra fosse proferida com apreciação da tese defensiva de nulidade da busca veicular e pessoal, fls.224/231.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de tráfico ilegal de entorpecentes.

A preliminar de nulidade da prova alegada pela defesa não prospera, eis que o policial relatou que estava em patrulhamento quando avistou um veículo, cujos passageiros se abaixaram ao notar a presença dos policiais; isso despertou a suspeita, de modo que o veículo foi abordado, os ocupantes revistados, entre eles o réu, em poder de quem as porções de droga foram localizadas; além disso, na delegacia o réu confessou que a droga apreendida era para seu uso, bem como para vender para sustentar seu vício, o que torna a questão levantada protelatória e sem qualquer fundamento.

Nesse sentido:

"ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 1500559- 92.2021.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante PAULO GHERARDI MARINHO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. Vencido o Relator sorteado, Exmo. Des. Marcelo Semer, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, vencedor, MARCELO SEMER (Presidente), vencido, MARCELO SEMER (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA. São Paulo, 8 de agosto de 2022. XISTO RANGEL RELATOR DESIGNADO Assinatura Eletrônica PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1500559-92.2021.8.26.0535 Comarca: Santa Isabel Apelante: Paulo Gherardi Marinho Neto Apelada: Justiça Pública Juiz: Carlos Eduardo de Moraes Domingos Voto nº: 7826 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Abordagem e busca pessoal que estão justificadas, pois de acordo com a lei: fundada suspeita (art. 244 do CPP). Policiais que apontaram de forma segura que, ao visualizar a aproximação da guarnição, o acusado,

que se encontrava sentado em uma guia num local conhecido como ponto de tráfico, adotou atitude evasiva, denotadora de fundada suspeita de que tivesse algo ilegal consigo. Desnecessidade, inclusive diante do encontro de drogas com ele e de ser desmentido quanto a estar em outro local, que os policiais expusessem de forma mais elaborada a suspeita que os levara à revista pessoal, que, bom que se diga, independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer momento, mesmo que não se trate de situação de flagrante (não há que se confundir busca pessoal com busca domiciliar). Expertise policial que merece ser prestigiada, assim como são os depoimentos dos agentes da lei. Prova segura da autoria e materialidade. Condenação bem aplicada, merecendo, a r. sentença, ser ratificada na forma do art. 252 do Regimento Interno inclusive no que tange à dosimetria, fixada com critério. Recurso não provido. Peço licença para reproduzir o relatório do r. voto do eminente relator sorteado: Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de fls. 195/202, que julgou procedente a ação penal, para condenar o réu Paulo Gherardi Marinho Neto a cumprir 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 583 dias-multa, no piso legal, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Em suas razões recursais (fls. 205/211), a defesa sustentou, em síntese, que (i) insuficientes são as provas no caso, havendo inegáveis dúvidas quanto à autoria, conforme os depoimentos prestados e provas colhidas; (ii) a negativa do réu é corroborada pelos depoimentos das testemunhas de defesa, quanto a PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ausência de revista pessoal efetuada. Pleiteou a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a fixação da pena no seu patamar mínimo. Contrarrazões às fls. 219/220. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 257/259 pelo desprovimento do recurso. Eis o relatório. Ao que consta o réu, ora recorrente, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, já que no dia 25/02/21, às 22h30, na Rua Ademar de Barros, 09, na cidade de Santa Isabel, estaria trazendo consigo, para fornecimento a terceiros, 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína (0,7g) e 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo cocaína em forma de crack (3,95g), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, listadas na norma integradora do tipo. Policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado em local conhecido por ser ponto de tráfico, ocasião em que, demonstrando nervosismo diante da aproximação da viatura, ele teria adotado atitude evasiva. Diante dessa fundada suspeita, os policiais deliberaram abordá-lo, ocasião em que, em revista pessoal, com ele localizaram 01 papelote com cocaína e 29 pedras de crack que estavam na cueca, além de localizarem R\$ 472,00, em espécie (dinheiro trocado) e um telefone celular. Indagado, Paulo teria admitido aos agentes da lei estar traficando. Após instrução probatória, sobreveio a r. sentença condenatória. A despeito das consistentes considerações do eminente relator sorteado quanto à invalidade da prova, no ponto respeitosamente divergimos. Explico por quais razões. Desde a fase do inquérito os policiais mencionaram que estavam em patrulhamento ostensivo e que, encontrando-se o réu em local já conhecido como ponto de tráfico, ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo, tentando se distanciar. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Em juízo inclusive explicaram que ele estava sentado na guia e adotou atitude evasiva, que lhes despertou suspeita. O policial Ednaldo, perguntado pelo Promotor, ainda disse: o local era conhecido pelo tráfico, e lá se depararam com o réu sentado numa guia e, diante da aproximação policial, levantou-se e passou a caminhar, em atitude que gerou suspeita. Exatamente no mesmo sentido foi o depoimento do policial Fernando, também conferido em mídia pelo e-saj. Enfim, há que se reconhecer que os policiais reportaram, ainda que do modo simples e direto que lhes é típico, que a atitude que então perceberam do acusado foi suspeita, indicativa de que ele tivesse algo consigo, no caso drogas, já que se tratava de ponto de tráfico. Não à toa que com ele realmente localizaram drogas. Inclusive sendo ele indivíduo reincidente, com condenação anterior justamente por tráfico. Exigir dos policiais que se refiram à suspeita com vocabulário mais elaborado, acredito que é exigir mais do que lhes cabe, já que não são profissionais propriamente versados em prolífica tradução, em palavras, da complexidade de nuances do comportamento humano. E se não lhes permitirmos que abordem quem lhes

parecer suspeito por adoção de atitudes que lhes são reveladoras de suspeição em razão da rica experiência adquirida (pressuposições empiricamente justificadas), fatalmente vamos lhes castrar a efetividade no enfrentamento à criminalidade, que grassa cada vez mais desinibida. É óbvio que o policial leva em conta na sua atuação, também ideias preconcebidas, afinal, são seres humanos adultos, dotados de formação e experiência que, no mais das vezes, os colocam inclusive a salvo de maiores perigos. Como lembrado pelo psiquiatra Theodore Dalrymple, não há como eliminar do homem todas as pressuposições habilitadas pelo prévio conhecimento cevado na experiência, pois o mundo não se recria na mente humana a cada dia, a cada momento: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Pessoas virtuosas de todo o mundo, ou ao menos na parte do mundo suscetível a entusiasmos morais e aos prazeres da culpa, tentam expurgar todo e qualquer preconceito de suas mentes, e saem mundo afora todas as manhãs com a mente fresca sabor hortelã, uma tábula rasa, da qual foram eliminados o conhecimento prévio e a experiência das pessoas e das coisas. É como se a vida virtuosa exigisse que se vivesse cada momento como se o mundo fosse recriado novamente, e nenhum momento tivesse qualquer conexão com qualquer outro momento cada minuto, cada segundo, cada fração de segundo ontologicamente separados. Em certo sentido, sem dúvida, é de fato uma grande virtude reter habilidade de se deixar surpreender novamente pelo mundo, e não ficar tão plantado na experiência e pelo cansaço da carne, de modo que o mundo se torne previsível e aborrecido. Mas caso encontrássemos um homem que expressasse espanto por janeiro estar mais frio do que julho (no hemisfério norte), e que insistisse em chamar nossa atenção para esse fato extraordinário, tomá-lo-íamos no mínimo como um tolo, e possivelmente como um louco. O modo mais eficiente de se tornar um chato, disse Voltaire, é dizer tudo ou seja, supor que nada pode ser dado como sabido...1 Logo, é indevido esperar que o policial seja ingênuo na identificação de certa conduta, por ele já visualizada em outras situações de tráfico, como denotadora de suspeição, pelo contrário, é louvável que tenha ganho, com a experiência, aludida expertise, a mesma que se verifica, por exemplo, quanto aos agentes policiais e alfandegários nos aeroportos quando elegem pessoas à revista por meio de leitura corporal que passa despercebida por gente comum. Imagine se fôssemos exigir dos policiais de fronteira muito palavrório e burocracia para justificar toda e qualquer revista? Imagine se fôssemos exigir o mesmo dos policiais que atuassem em blitzes da lei seca ou no combate a ações terroristas? Por falar em lei seca, cabe lembrar que a palavra dos policiais (prova testemunhal) é tomada como apta inclusive para atestar a alteração da capacidade psicomotora do condutor (art. 306, par. 2º, do CTB), o que é instrumento bastante importante especialmente quando este não aceita se submeter voluntariamente 1 Theodore Dalrymple: "Em defesa do Preconceito. A necessidade de se ter ideias preconcebidas". "É Realizações editora, 2015, p. 91. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO aos testes de aferição de alcoolemia. Aliás, também é preciso lembrar que a busca pessoal não tem a mesma estatura da busca domiciliar, esta sim, condicionada pela Constituição (art. 5º, XI) à prévia expedição de mandado judicial. Para a busca pessoal, que pode ser realizada de dia ou de noite, independentemente de prévia expedição de mandado, nem é preciso que esteja, o seu alvo, em situação de flagrante! E voltando ao nosso caso, ponto importante a ser observado é que, em oposição à versão policial, a do réu soou totalmente descabida, visto dizer que estava dentro do bar e que um outro indivíduo havia corrido do lado de fora e jogado a droga, que lhe fora atribuída gratuitamente pelos policiais que nem conhecia. Referida estória além de inacreditável não se sustenta, pois na prova inexistente qualquer referência a outra pessoa, e nem o dono do bar confirma que o réu estivesse dentro do estabelecimento quando abordado. Além do mais os policiais o desmentem com firmeza (sem que se tenha demonstrado razão para que mentissem e a ele atribuísem droga que não estivesse consigo). E assim como não se tem razão para suspeitar gratuitamente dos depoimentos dos policiais no tocante ao encontro da droga com o acusado, não se tem razão para duvidar que a abordagem se dera em razão de fundada suspeita. Mesmo porque, não fosse a atitude do réu a provocar a suspeita, não teriam como antever que ele estava com as drogas, efetivamente com ele encontradas. Por outro lado, o discurso trazido na

jurisprudência mencionada pelo nobre relator sorteado (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022), de vitimização de pessoas da periferia, que estariam mais propensas a sofrer abordagem policial, embora respeitável, não nos convence da ilegalidade da atuação policial, já que esta merece ser analisada no caso concreto, pois o que se julga é o caso, não um estudo, uma tese ou uma teoria. A propósito, aqui cabe abrir um parêntesis, pois identifico no discurso mencionado a mesma gênese daquele que dá voz às críticas à confiança que PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO a lei atribui à avaliação subjetiva levada a efeito pelo policial e pelo julgador quando se trata de distinguir o tráfico da posse de drogas para uso próprio. Segundo essas vozes, o sistema de avaliação policial judicial (mais subjetivo) da nossa lei (art. 28, par. 2º, da Lei 11.343/06) deveria ser substituído pelo da quantificação legal (objetivo), já que os profissionais do direito que atuam na repressão ao crime, embebidos de seus preconceitos (ainda que inconscientes ou “estruturais”) contra gente pobre e de pele mais escura, acabaria por tender a lhes atribuir com maior probabilidade o tráfico do que o porte para uso próprio, a despeito de serem similares as circunstâncias objetivas. Tanto por isso, para o Ministro Gilmar Mendes, a despenalização da conduta do usuário de entorpecentes não seria suficiente ao seu mais correto enfrentamento já que, persistindo o enquadramento criminal, com ele persistindo a inadmissível “seletividade do sistema” em prejuízo dos mais vulneráveis (“zona cinzenta da interferência estatal”), prejudicada ficaria a implementação das políticas de redução de danos e prevenção de riscos: Na prática, porém, apesar do abrandamento das consequências penais da posse de drogas para consumo pessoal, a mera previsão da conduta como infração de natureza penal tem resultado em crescente estigmatização, neutralizando, com isso, os objetivos expressamente definidos no sistema nacional de políticas sobre drogas em relação a usuários e dependentes, em sintonia com políticas de redução de danos e de prevenção de riscos já bastante difundidas no plano internacional.² Tal abordagem nos traz à lembrança as inconsistentes teorias criminológicas do labelling approach, segundo as quais é atribuída à intervenção da justiça criminal a maior responsabilidade pelo aprofundamento da criminalidade. A conduta desviada teria origem, então, mais na sociedade do que propriamente no indivíduo, de modo que o desvio, por assim dizer, não seria algo atribuível a quem o comete, mas uma consequência da aplicação, em si, das regras e sanções para o ofensor.³ Eis mais uma forma de culpar a sociedade pelas agressões ² Disponível em: www.conjur.com.br/dl/re-posse-drogas-para-consumo-voto-gilmar.pdf (acesso em 29/06/2018). Voto proferido no RE 635659/SP. ³ Ver menção em SHECAIRA, Sérgio Salomão, “Criminologia”, RT, 6ª edição, 2ª tiragem, 2014, p. 258. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cometidas contra ela própria⁴. Mais um meio de justificar o crime e o criminoso com base em um ethos de secular relativismo ou, até, mediante exercício de preconceito moral invertido. Um crime, segundo essa corrente, não devendo mais ser encarado ou denominado como crime. Um delinquente também não podendo mais ser chamado de delinquente. Devendo ser abolida a tradicional terminologia que, dada a carga pejorativa, seria tida como aderente e estigmatizadora do indivíduo, este absolutamente intangível em sua dignidade bandida. A propósito, segundo os arautos da vitimização do infrator, agindo como facínoras, juízes, promotores e policiais tendem a ser mais rigorosos na classificação do delito quanto mais preto, pobre e marginalizado for o sujeito submetido ao seu poder. Atuando, pois, como agentes de reforço da rotulação que acaba por alimentar de forma espiral o sistema penitenciário. Referida inferência é, segundo penso, leviana. Primeiro porque parte do pressuposto de que os profissionais do direito que atuam na persecução o fazem com má índole, com abjeta discriminação. Segundo porque é calcada em indevida associação de causa e efeito, com base em estatísticas discutíveis que podem nos levar a erros de dedução. Ora, mesmo que no universo de indivíduos detidos como traficantes haja mais negros, mulatos e pobres (em desproporção com sua representação no cômputo geral da população), somente isso não é suficiente para associar coisa com outra, ou seja, para afirmar que a polícia tanto mais endurece sua atuação repressora quanto mais escura seja a cor da pele e minguada a conta

bancária do sujeito alvo de sua atuação. Até porque, onde está a demonstração de que, em função da natureza dos crimes cometidos e de seus respectivos autores, outra devesse ser a expressão proporcional de prisões e condenações? É preciso cuidado com a transposição do onipresente discurso do oprimido e do opressor, hoje perpassado pelo racismo. Ele não serve à análise adequada de toda e qualquer situação, menos ainda quando apoiado só em simplória associação monofatorial. 4 Ver a respeito a notícia publicada no site G1, política, a respeito de absolvição de traficante detido com 6 kg de cocaína no aeroporto de Brasília. O juiz teria entendido, segundo se afirma, que não haveria como culpar o réu, já que suas condições pessoais e familiares (dificuldades econômico-financeiras) não teriam permitido que ele agisse de outro modo. Disponível em: g1.globo.com/politica/blog/matheus-leitao/post/2018/07/27/juiz-absolve-equatoriano-presos-com-quase-6kg-de-cocaína-no-aeroporto-de-brasília.ghtml. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Adotássemos tal entendimento, haveríamos então que concluir que quanto à criminalidade do colarinho branco, notadamente aquela que fora alvo da operação lava-jato e afins, haveria, por parte dos profissionais que atuam na área criminal, perseguição contra homens brancos e ricos, já que praticamente 100 por cento dos indivíduos que foram alvos das prisões/condenações/investigações em tais casos eram pessoas com tais características. Dando para ver, então, o nível de mistificação que infelizmente vira clichê mesmo entre gente mais culta. Enfim, é preciso cuidado com o manejo desse discurso binomial e singelo que em vez de se apoiar em abalizados critérios, lastreia-se em viés panfletário a serviço de insidiosa ideologia. Discurso que por ignorar a complexidade e variedade de fatores interagentes na realidade do crime acaba por disseminar a empulhação de que a atuação repressora do Estado não é mais do que expressão de mero preconceito burguês a serviço da exploração do mais fraco pelo mais forte (a eterna luta de classes). É preciso, pois, monitorar constantemente a validade lógica dos argumentos criminológicos para não cairmos na “falácia da afirmação do consequente” assim exemplificada por NISBETT: “Se eu tenho febre, então estou com a garganta inflamada. Estou com a garganta inflamada. Logo, estou com febre”⁵. O que atraído para o nosso tema poderia ser assim traduzido: se o sujeito foi preso e é negro, ele deve ser vítima de injustiça. Como sou branco e estou preso, minha prisão deve ser justa. Ou ainda: se há na população em geral 55 por cento de pretos e pardos, qualquer percentagem maior de tal categoria observada na população carcerária seria produto de racismo. Uma coisa é incentivar à polícia adoção de protocolos e critérios mais objetivos que permitam ao juiz se fiar em mais do que só na palavra de seus agentes. Outra, bem diferente, é deslegitimar toda e qualquer interferência policial por prévia suspeição quanto à lisura de seu proceder. Tanto que a jurisprudência a respeito do tema é iterativa. Confira-se: STJ - ...esta Corte tem entendimento firmado de que os 5 NISBETT, Richard “MINDWARE, Ferramentas para um Pensamento mais Eficaz”, ed. Objetiva, 2018, p. 239. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese - AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC. A palavra dos policiais, assim como vale para dar atestado do que presenciaram e do que apreenderam com o acusado, vale para justificar a abordagem e a fundada suspeita, cuja prova decorre menos do quanto sejam versados na elaboração vernacular do que presenciaram⁶ - e logicamente não filmaram⁷ -, e mais do que efetivamente encontraram. Ou seja, não há maior atestado de que a suspeita era fundada do que o encontro da droga com o sujeito alvo da busca pessoal e a consequente prisão em flagrante! É mais ou menos o mesmo raciocínio que se emprega, por exemplo, nos casos de violência doméstica, quando indefectivelmente a jurisprudência se inclina, a despeito da negativa de autoria por parte do réu e de ausência de testemunhas presenciais, para a condenação do acusado, já que com o laudo pericial atestando a lesão, a palavra da vítima é tomada como prevalente. Ora, se o laudo atestando a lesão faz prevalecer a palavra da ofendida (pessoa não desinteressada na solução da causa) à do réu (este presumido inocente), por qual razão o encontro da droga com o acusado e sua prisão

em flagrante não faz presumir como realmente fundada a suspeita que levou os policiais à pronta intervenção? Além do mais, se fosse tomar então como abusiva a atitude dos policiais, como feito no voto do eminente relator, seria preciso, segundo pensamos, decidir por inteiro, identificando que fatores preconceituosos ou ilegítimos teriam levado à busca pessoal indevida, determinando-se, em consequência, responsabilização dos agentes da lei. Ou seja, precisaria ser analisado o caso concreto. 6 Assim como se costuma afirmar não se poder olvidar que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si, não sendo necessário que a decisão seja extensa ou que possua minudência exaustiva, também se pode afirmar quanto ao policial que justifica a fundada suspeita para a abordagem do suspeito, notadamente quando o seu resultado for positivo, ou seja, confirmatório do acerto da suspeição. 7 Nem todo policial está equipado com body-cam. E, mesmo assim, há percepções fugazes e que extrapolam o campo de captura de imagens dos aparelhos de reprodução visual. E a LEI, por ora, não exige como condição validadora da atuação da polícia, que ela seja registrada em filme. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Quanto ao mais, a prova do aspecto material do crime encontra estofo no laudo encartado a fl. 103/114, que confirmou a constatação preliminar. Não foi muita droga, mas também não foi pouca que justificasse que o réu, pessoa já condenada por tráfico, então a tivesse, naquele local e circunstâncias (apreensão de dinheiro trocado e diversas porções embaladas individualmente), somente para consumi-la. A autoria, como visto, é demonstrada, não servindo a afastá-la a menção ao que disseram as testemunhas de defesa. Como dito na r. sentença, cujos fundamentos ficam aqui ratificados na forma do art. 252 do Regimento Interno, nada disseram que infirmasse a diligência policial. Note-se que as testemunhas não presenciaram propriamente a revista feita no acusado, que se deu fora do bar, não dentro dele como quis fazer crer o acusado quando foi interrogado. Friso: o réu a um lado afirma ter sido abordado pelos policiais dentro do bar, onde só assistia a um jogo e tomava uma cerveja. A testemunha Cosmo, por ele arrolada diz que a abordagem do réu se deu fora do bar, sem fazer qualquer referência ao fato de ele se encontrar no bar a tomar cerveja ou a assistir a um jogo, tanto que o senhor Cosmo, proprietário do bar, disse que já o estava fechando. Enfim, com o devido respeito à divergência, o voto é no sentido de que a prova seja tomada como válida e, por conseguinte, ao analisá-la, eu mantenho a condenação com os mesmos fundamentos da sentença. Vejamos a dosimetria. A pena base foi fixada corretamente no mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A reincidência acarretou um aumento de 1/6 que as elevou a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, nível no qual ficou definida à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas. Não reconheço atenuante da confissão. O réu não confessou a prática delitativa em juízo. Nem o fizera na presença da autoridade policial, como se pode verificar a fl. 12. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E não era caso mesmo de aplicar o redutor, pois a reincidência inclusive é específica, como se pode perceber da certidão de fl. 183, assim acabando por justificar, inclusive, o regime escolhido, o fechado. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, ficando mantida, a r. sentença recorrida, na sua integralidade. XISTO RANGEL RELATOR DESIGNADO".

A materialidade restou incontroversa ante a apreensão das drogas e o laudo acostado aos autos.

O réu é revel.

O policial ouvido em juízo narrou que em patrulhamento pelo local se deparou com um veículo com vários ocupantes e que as pessoas no banco traseiro tentaram se abaixar quando viram a viatura; que em razão dessa atitude abordou o veículo e seus ocupantes; que o réu tinha em seu poder 20 pedras de crack prontas para a venda e uma porção maior da mesma droga; que ele confessou que iria vender as pedras menores e fracionar a maior para a venda nos mesmos moldes.

Finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito.

A quantia de droga encontrada, as circunstâncias da prisão e as declarações do policial evidenciam a finalidade de tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Vale citar:

“Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas” (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288).

Vale dizer que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas.

Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito.

Vale, ainda, mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos de policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: “ nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória.” (Ap.Crim. 103.701 TJSP).

“ a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida” (STF - RT 68/64).

“ não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrasenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. ” (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Por outro lado, considerando que o réu é tecnicamente primário, é possível reconhecer a favor dele a causa de diminuição de pena do art. 33 parág. 4º, o que será feito no momento processual adequado.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu RAFAEL IGOR FERREIRA MENDES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos.

Fica decretado o perdimento dos bens e objetos apreendidos nos termos da Lei de Tóxicos.

DOSIMETRIA DA PENA.

Atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber: CINCO ANOS DE RECLUSÃO e multa de QUINHENTOS DIAS MULTA, cada qual no seu mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes.

Presente uma atenuante decorrente da confissão cuja consideração resta prejudicada em face da fixação da base em seu mínimo. Inexistem causas de aumento de pena.

Presente uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 33 parág. 4º da Lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos ali exigidos, diminuo em 2/3 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA.

Não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda torno DEFINITIVA A PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Nos termos do art. 44 do Código penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE e MULTA DE DEZ DIAS MULTA, ante o entendimento das Cortes Superiores.

Ante a substituição retro operada, inviável a suspensão condicional da pena.

Nos termos do art. 33 parágrafo 3º do CP, fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, para o caso de conversão, o REGIME ABERTO.

O réu foi colocado em liberdade durante o curso do feito, assim, nada indica necessidade de alteração da situação atual, nos termos do parág. único do art. 387 do Código de Processo Penal, com a redação que foi dada pela Lei 11.719/08.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providenciem-se o necessário para efetivo cumprimento das sanções impostas e arquivando-se os autos com as cautelas devidas.

P.I.C.

Itapetininga, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA